

1500021-09.2019.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... usadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado se estiverem conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividades criminosas ou integração a organização criminosa: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500021-09.2019.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500021-09.2019.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DOS SANTOS GONÇALVES-matricula nº 0997008-8

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

LUAN DOS SANTOS GONÇALVES (fls. 53) foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c. c. art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06 (fls. 63/64).

Isso porque, segundo consta, na manhã de 05 de janeiro de 2019, por volta das 10h30min, na Penitenciária João Batista de Santana, na cidade de Riolândia, Comarca de Paulo de Faria, o acusado, agindo em concurso, previamente ajustado e em unidade de desígnios com a adolescente Daniele Ribeiro Mendonça (nascida em 25/07/2001), trazia consigo e ocultava para fins de tráfico 74,7g de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 8/9 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 17/19).

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: Daniele Ribeiro Mendonça (fls. 10); Agente Penitenciário Ivair Márcio de Souza (fls. 06) e Agente Penitenciário Janaína Ribeiro Viel (fls. 07).

Notificado pessoalmente (fls. 77), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 83/84), por defensor nomeado (fls. 78), pedindo absolvição e arrolando as mesmas testemunhas de acusação.

A denúncia foi recebida (fls. 101/102), sendo realizada audiência de instrução (fls. 215/216).

As partes apresentaram alegações finais escritas. O Ministério Público pediu a

condenação nos termos da denúncia (fls. 253/259), ao passo que a Defesa pediu absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 262/265).

É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), termos de depoimentos e interrogatório (fls. 06, 07, 10 e 50), auto de exibição e apreensão (fls. 08), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), auto de apreensão de adolescente (fls. 11/12), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 117/19) e controle de visitas (fls. 247).

Por sua vez, a prova produzida sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação. Conforme a denúncia:

Segundo se apurou, a adolescente ocultou a porção da droga mencionada acima dentro de várias panquecas e tentou entrar no presídio com ela para entregá-la ao denunciado Luan, seu companheiro que ali se encontrava recolhido.

Ocorre que, durante a revista de praxe nos alimentos, os agentes penitenciários encontraram os pedaços de maconha amassados e camuflados no recheio das panquecas. A expressiva quantidade de droga apreendida, a maneira como estava acondicionada e as circunstâncias da prisão, denotam que a mercadoria se destinava ao tráfico no interior do estabelecimento prisional.

O denunciado agiu em concurso de pessoas com a menor, pois a droga seria entregue por Daniele a ele, que a venderia no local.

Foram apreendidos: uma embalagem plástica transparente com tampa verde contendo macarronada e panqueca recheada aparentemente com maconha e 74,7 gramas de maconha acondicionadas em 74 invólucros.

O laudo de exame químico-toxicológico apontou resultado positivo para: tetrahidrocannabinol - THC nas amostras colhidas de uma porção de fragmentos vegetais.

A testemunha Agente Penitenciário Ivair Márcio de Souza relatou que a vasilha de panqueca estava recheada com maconha e, ao ser indagada, a adolescente disse para o depoente que foi a pedido do acusado. A maconha estava solta e no lugar do recheio da panqueca. Não se recorda da adolescente de outras ocasiões. Essa foi a segunda apreensão no dia.

A testemunha Agente Penitenciário Janaina Ribeiro Viel, narrou que a adolescente iria visitar o companheiro e estava sendo realizada revista própria na sala de alimentação, quando o Agente Ivair verificou a existência da substância na comida e chamou a depoente. A depoente viu a substância no meio da alimentação e, ao questioná-la, a adolescente disse que tinha feito aquilo a pedido do companheiro, que era para entregar para ele. Não tem contato com o sentenciado. Não se lembra da adolescente. Depois da revista de alimentação fez a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Não se lembra da adolescente de outra ocasião. A visita é exclusiva para o preso e é delimitada a quantidade e o que pode ou não pode entrar. Não é permitido fazer visita para outro preso. Houve outra apreensão no mesmo dia para outro visitante. Não sabe responder se havia troca de comida porque atua apenas no momento da revista.

A testemunha Daniele Ribeiro Mendonça afirmou que estava levando arroz e salgadinho para o acusado e uma moça a abordou na fila, pedindo-lhe para entregar a marmitta dela, que era panqueca, ao marido dela. A depoente pediu para a moça abrir o recipiente e não viu nada. Depois o agente falou que havia droga na comida e a depoente ficou chocada. A depoente já havia feito outras visitas.

Em seu interrogatório o acusado negou a acusação, afirmando que só tomou conhecimento dos fatos após o castigo, não iria fazer algo para se prejudicar e a sua companheira agiu por ter se sentido comovida.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que o delito está efetivamente caracterizado, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

Durante a revista na alimentação levada pela companheira do acusado, os agentes penitenciários perceberam a existência de maconha escondida dentro do recheio da panqueca e, ao a indagarem sobre o assunto, ela admitiu que pretendia entregar a

droga para o acusado, a pedido dele, dentro da unidade prisional.

Por sua vez, o controle de visitas comprovou que a companheira e a mãe do acusado eram as únicas pessoas cadastradas para visitá-lo.

Diante disso, é incabível supor que uma pessoa desconhecida teria se valido da suposta ingenuidade da companheira do acusado para tentar concretizar a entrega da droga a terceiro recluso não identificado, sabendo que poderia correr o risco de perder o entorpecente e sofrer consequências do meio criminoso.

Vale dizer ainda que o simples fato de as testemunhas serem agentes penitenciários, por si só, não tem o condão de enfraquecer seus depoimentos, os quais devem ser valorados com isenção e em cotejo com os demais elementos probatórios:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Sequer há motivo para se imaginar que os agentes ou terceiras pessoas desconhecidas pretendessem incriminar o acusado falsamente, mesmo porque houve outra apreensão no mesmo dia, ou seja, trata-se de fato rotineiro.

Por sua vez, a Defesa do acusado não conseguiu demonstrar a falibilidade dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, não basta apenas argumentar que é incabível presumir a culpa do recluso apenas por ser o destinatário da visita. É preciso ir além das teses, oferecendo-se explicação concreta para os fatos. A versão apresentada pelo acusado precisaria ser verossímil e não foi, pelos motivos expostos.

Ressalte-se também que nada impede que a traficância ocorra em paralelo com o uso de drogas e/ou com o exercício de ocupação lícita, razão pela qual tais alegações não afastam a caracterização da conduta típica. Isso porque o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 caracteriza-se como tipo misto alternativo, de maneira que basta que o agente incorra em qualquer das condutas ali descritas, dentre elas a de trazer drogas consigo, sem autorização, como descrito na denúncia.

Ademais, a existência de revista pessoal no estabelecimento prisional não torna impossível a consumação do crime. O crime impossível se caracteriza apenas se o meio escolhido para o agente for absolutamente inidôneo para provocar o resultado típico (art. 17 do CP). Ainda que a revista se destine a evitar a entrada de celulares e drogas na unidade, não é absolutamente infalível e falhas do próprio sistema prisional permitem que isso ocorra. Sobre o assunto:

Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos, drogas, aparelhos celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza o ingresso de tais objetos no presídio (HABEAS CORPUS nº 575554 - SP, RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27 de abril de 2020).

Logo, resta bem caracterizada a conduta delitativa, como também o concurso de agentes e a unidade de desígnios para sua consumação.

No mais, vale mencionar que a companheira do acusado recebeu remissão pelo fato praticado porque completou a maioridade durante o processo destinado à sua apuração (Proc. 1500046-23.2019.8.26.0559).

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição). Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser "necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, "O juiz,

na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (art. 42).
Prevalece na jurisprudência que, por serem circunstâncias preponderantes e devido à vedação ao bis in idem, a natureza e a quantidade de entorpecente devem ser valoradas apenas na primeira fase da dosimetria e só podem ser usadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado se estiverem conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividades criminosas ou integração a organização criminosa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.
2. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elege-se dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.
3. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.
4. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.
5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.
6. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.
7. A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 687.767/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)
PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo

exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeesse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

O delito de tráfico é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto e a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, conforme o montante aplicado (menor que 4 anos, maior que 4 anos e menor que 8 anos ou maior que 8 anos) e a presença ou não de reincidência e antecedentes (art. 33, caput e §2º, do CP, Súmulas 269 e 440 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF).

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui condenações transitadas em julgado para a Defesa em 04/05/2016, 09/05/2017, 30/08/2018 e 22/01/2020 (data do fato: 01/03/2018) (fls. 150/155).

Conforme o entendimento jurisprudencial, as condenações por fatos posteriores ao descrito na denúncia não caracterizam antecedentes e condenações antigas podem ser

valoradas negativamente porque os antecedentes não se sujeitam ao prazo depurador de 5 anos aplicável à reincidência (art. 64, I, do CP)

A jurisprudência atual desta Corte, sedimentada no Enunciado de Súmula 444, veda às instâncias inferiores valorar negativamente a pena-base em função de inquéritos ou processos em curso, sem trânsito em julgado, em respeito ao princípio da presunção de não culpa. Ainda, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa. (HC 443.678/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. (HC 433.543/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA.

CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM

OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes

condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo

quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso

concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da

individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se

aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818, Relator(a):

ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)

A situação concreta caracteriza multirreincidência, motivo pelo qual as condenações, desde que distintas, podem ser utilizadas tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria:

Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas

como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os

mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte. (AgRg no AREsp 1439346/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

A jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de que, considerando a multirreincidência do agente, é possível a utilização de condenações pretéritas

distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da

reincidência (AgRg no HC 460.888/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 21/03/2019)

Assim, a primeira condenação mencionada deve ser utilizada para caracterizar a reincidência, que é circunstância agravante, a ser valorada na segunda fase (Súmula 241 do STJ), enquanto as demais devem ser valoradas negativamente como

circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ainda de acordo com a jurisprudência, "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser

valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em

23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Diante disso e na falta de elementos em sentido contrário, a conduta social e personalidade do acusado; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não devem ser valorados negativamente.

Por sua vez, a natureza e quantidade de droga encontrada apenas corroboram a caracterização do tráfico, não justificando a exasperação da pena-base.

Conforme a jurisprudência, em regra, é razoável exasperar a pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, porém, é possível aplicar fração superior para a valoração de um único vetor, se preponderante:

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (AgRg no HC 666.280/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Logo, mostra-se proporcional caso concreto exasperar a pena-base em 1/6, o que resulta em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, pelo antecedente mencionado, motivo pelo qual a pena deve ser exasperada em 1/6, o que resulta 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena, mesmo porque a reincidência afasta o privilégio (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Presentes as causas de aumento descritas no art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06, uma vez que a prática delitiva ocorreu nas dependências de unidade prisional e em concurso de agentes com adolescente. Consequentemente, a pena deve ser aumentada de 1/6 a 2/3.

Considerando que o tráfico ocorreu dentro da unidade prisional, e não apenas nas imediações, mostra-se proporcional aumentar a pena em 1/3, o que resulta em 9 anos e 26 dias de reclusão e 906 dias-multa.

Assim, torno definitiva a pena no patamar acima.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Cabe reconhecer que o tráfico é crime equiparado a hediondo (art. 2º da Lei 8.072/90 e Súmula 510 do STJ), mas a hediondez por si só não justifica a imposição de regime fechado (Tema 972 da repercussão geral do STF), surtindo efeitos apenas na esfera de execução da pena.

Pelo montante (maior que 8 anos) e devido à reincidência, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a, do Código Penal).

Pelo montante da pena (maior que 4 anos), incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR LUAN DOS SANTOS GONÇALVES à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 906 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c. c. art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06 c. c. art. 61, I, do Código Penal.

Por não mais interessarem ao processo, determino a destruição das drogas apreendidas (art. 72 da Lei 11.343/06). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Após o trânsito em julgado certificado, determino a restituição da embalagem apreendida à testemunha Daniele Ribeiro Mendonça, por, apesar de se tratar de instrumento do crime, não consistir em coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou

detenção constitua fato ilícito (art. 91, II, a, do CP e art. 118 do CPP, interpretado a contrario sensu). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça.

O acusado responde ao processo preso por outro juízo, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Portanto, ele faria jus ao direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não devesse ficar preso (art. 387, §§1º e 2º, do CPP).

Decorrido o prazo recursal, expeça-se a certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 15, III, da Constituição e art. 398 das NSCGJ), o mandado de prisão e, após, seu cumprimento, a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ); bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Expedida a guia, ela deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução mediante lançamento da movimentação "processo findo", com a situação "suspenso" (art. 468, §3º, das NSCGJ), certificando-se nos autos. Após, nada mais restando a deliberar, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Intime-se.

Paulo de Faria, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA